

1518697-24.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Franklin Regueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... que se encontrava trabalhando no tráfico ilícito de drogas, na função de "olheiro", mediante o pagamento de R\$ 100,00 por dia trabalhado, tornando certo e incontestável seu envolvimento no tráfico ilícito de drogas. Observe-se que, "Apesar de não praticar qualquer das figuras descritas no artigo 33 da lei 11343/06, aquele que garante a realização de qualquer dos atos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, 1º Pav., Rua 10, sala 329, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7171, São Paulo-SP - E-mail: sp29cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:1518697-24.2022.8.26.0228 - 2022/000988Classe - AssuntoProcedimento Especial da Lei AntitóxicosRéu:KAIO GABRIEL FERNANDES DO NASCIMENTO

Aos 26 de outubro de 2022, às 13:30 HORAS, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, na sala de audiências virtuais da 29ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, Doutora Tatiana Franklin Regueira, comigo Assistente, foi declarada aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento designada nestes autos. Apregoados, compareceram o (a) Digníssimo (a) Promotor (a) de Justiça, Dr. (a) Maria do Carmo Galvão de Barros Toscano, o réu KAIO GABRIEL FERNANDES DO NASCIMENTO e seu(sua) Defensor(a) Dra. Tatiana Cristina Anzolin Pinto Michels. Declarações e depoimento(s) colhido(s) pelo sistema audiovisual, gravados na plataforma Teams, com a concordância dos presentes. A qualificação dos presentes foi, nesta data, atualizada no sistema eletrônico e se encontra à disposição das partes, com as ressalvas do Provimento CG 32/2000, em se tratando de vítima ou testemunha protegida. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas Alexandre e Antonio, policiais civis, após o que o réu foi interrogado. AS PARTES NÃO SE OPUSERAM QUE A AUDIÊNCIA OCORRESSE PELO SISTEMA PRESIDENCIALISTA, bem como não se opuseram que a audiência ocorresse de forma remota. Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, por ele (ela) foi dito que: MMª Juíza, nada a requerer na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Pela Defesa foi dito que: : MMª Juíza, nada a requerer na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Em seguida, pela MMª Juíza de Direito foi dito: Não havendo outras diligências a serem empreendidas nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, dou por encerrada a instrução criminal, iniciando-se os debates.

Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, por ele (ela) foi dito que: MMª Juíza, KAIO GABRIEL FERNANDES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 18 de agosto de 2022, no horário e local descritos na inicial, trazia consigo e mantinha sob guarda, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 60 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 95,3g e 221 porções de cocaína, com

peso líquido de 212,2g, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica. Encerrada a instrução probatória, verifica-se que, a presente ação penal deve ser julgada TOTALMENTE PROCEDENTE. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação (fls. 20/23), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 94/96), bem como pela prova oral colhida. A autoria delitiva e a prática de traficância também se mostram certas e inquestionáveis. Senão, vejamos. Quando interrogado na fase inquisitorial, o réu negou que estivesse comercializando drogas no local, alegando que trabalhava no tráfico apenas na função de “olheiro”. Em Juízo, manteve a mesma versão, admitindo estar na função de olheiro para os outros dois indivíduos que efetuavam a venda dos entorpecentes. Os policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, ouvidos em solo policial, ratificaram seus depoimentos prestados em solo policial. O policial Alexandre relatou que, na data dos fatos, ele e seu colega de equipe estavam em operação visando o combate ao tráfico ilícito de drogas. Realizaram incursão em local já conhecido como ponto de venda de drogas. Visualizaram alguns indivíduos se comunicando com outros dois indivíduos que se encontravam na parte superior de um imóvel desabitado. Observaram que os indivíduos que se encontravam na parte superior do imóvel controlavam a descida de uma corda com metade de uma garrafa pet presa na ponta, mecanismo conhecidamente utilizado para venda de entorpecentes nas comunidades. Ao notarem a aproximação da equipe, os indivíduos empreenderam fuga correndo, tomando direções diversas. O acusado era um dos indivíduos que se encontrava na parte superior da edificação e também tentou empreender fuga escorregando por um cano de água fixado no imóvel. Contudo, ele veio a se desequilibrar e caiu no chão, possibilitando sua captura. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi localizado em seu poder. No entanto, ao verificarem a parte superior do imóvel onde o acusado foi visto inicialmente, localizaram uma sacola plástica preta contendo inúmeras porções de cocaína e maconha, individualmente embaladas e prontas para a venda. Indagado, o acusado disse que ganhava 100 reais por dia para trabalhar no local como olheiro. A sacola foi encontrada na parte superior do cômodo onde apenas o acusado e o outro indivíduo que fugiu tinham acesso. No mesmo sentido, o depoimento do policial José Antônio. Confirmou ter visto o réu na parte superior do imóvel onde os entorpecentes foram localizados. Acrescentou que não conheciam o acusado antes do ocorrido. Os depoimentos dos policiais, além de coesos e harmônicos entre si, não foram desconstituídos por qualquer elemento de prova, sendo aptos e mais do que suficientes a embasar o decreto condenatório. Ambos confirmaram terem visto o acusado no local onde os entorpecentes foram localizados (parte superior do imóvel desabitado), na companhia de outros indivíduos, manuseando uma corda presa a uma garrafa pet, mecanismo comumente utilizado para a venda de entorpecentes nas comunidades, bem como que ele tentou empreender fuga ao notar a presença da equipe policial. Ressalte-se que, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu que “é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372). Merece, pois, total credibilidade os depoimentos apresentados pelos policiais, uma vez que não conheciam o acusado anteriormente, não possuindo qualquer interesse em incriminá-lo, imputando-lhe falsamente a prática de crime. A par disso, o próprio acusado, em sede policial, confirmou que se encontrava trabalhando no tráfico ilícito de drogas, na função de “olheiro”, mediante o pagamento de R\$ 100,00 por dia trabalhado, tornando certo e incontestável seu envolvimento no tráfico ilícito de drogas. Observe-se que, “Apesar de não praticar qualquer das figuras descritas no artigo 33 da lei 11343/06, aquele que garante a realização de qualquer dos atos descritos no preceito primário do artigo supracitado, concorrendo para o tráfico de drogas, deve ser penalmente responsável como coautor ou partícipe do crime, em sintonia com a teoria monista do concurso de agentes, prevista no artigo 29 do Código Penal. Incabível o pleito defensivo no sentido de enquadrar a conduta do apelante no

artigo 37 da lei n. 11.343/06 que tipifica a ação de colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer do crime de tráfico de drogas, pois o intuito do legislador, ao adotar no tipo penal do artigo 37, da lei 11343/03, a teoria pluralista do concurso de agentes não foi a de alcançar aqueles que exercem funções habituais no tráfico, como o "olheiro", pois este é coautor da conduta descrita no artigo 33, mas sim aqueles que normalmente não integram a associação criminosa, em suas diversas funções hierárquicas, mas acabam colaborando com informações privilegiadas e estratégicas para o exercício da traficância" (Apelação Criminal 1.0024.13.106127-7/001, 4ª Câmara Criminal, rel. Julio Cezar Guttierrez, DJ 12.03.2014). Desta forma, floresce cristalina a conduta do acusado, sendo de se salientar que a prática concreta do ato de mercancia não é elemento nuclear do crime de tráfico. Isso porque, muito embora o delito insculpido no artigo 33 da Lei de Tóxicos seja conhecido como "tráfico de entorpecentes", verdade é que nem todas as ações nele descritas – lembrando-se que estamos diante de um crime de ação múltipla – exigem o ato de comércio para sua consumação. Este o caso dos núcleos "trazer consigo", "ter em depósito" e "guardar". Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal "a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª turma – GC n. 69.806/GO, Rel. Ministro Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 4 de junho de 1993, p. 11.012). Desse modo, comprovada a materialidade e a autoria do delito, a condenação do réu é medida que se impõe. Em relação a dosimetria da pena, verifico que o acusado é primário e não ostenta antecedentes criminais. Diante da primariedade do réu e ausência de antecedentes criminais, não há óbice à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas. Contudo, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendida, a redução deve se dar no patamar mínimo. O regime inicial de cumprimento de pena pode ser o aberto, com possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Nestas condições, requer o órgão do Ministério Público a procedência da ação, condenando-se o réu nos exatos termos da denúncia.

Dada a palavra ao (à) Dr. (A) Defensor (A), por ele (ela) foi dito: alegações orais.

A seguir, pela MMª Juíza de Direito, foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Kaio Gabriel Fernandes Do Nascimento, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque supostamente no dia 18 de agosto de 2022, por volta das 15hs.01min., na Rua Domingos Sequeira, nº 314, Pirajussara, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 60 (sessenta) porções de "maconha", com peso líquido de 95,3g (noventa e cinco gramas e três decigramas) e 221 (duzentas e vinte e uma) porções de "cocaína", com peso líquido de 212,2g, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida (fls.70/73), o réu foi pessoalmente citado (fls. 111), apresentou resposta por escrito (fls. 114/115) e, não sendo caso de absolvição sumária foi admitida a instrução criminal (fls. 117), momento em que ouvidas duas testemunhas e o réu interrogado. Ao final, realizaram-se os debates. É o relatório do essencial. Fundamento e Decido. A ação penal é procedente. Assim porque ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório. A materialidade do delito está comprovada através do auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, auto de constatação (fls. 20/23), bem como laudo químico toxicológico (fls.94/96) e fotografias de fls. 35/37. A autoria também é indubitável. Coram judice o réu confessou que foi contratado pelo valor de R\$ 100,00 por dia por Lúcio e Vinicius que realizavam a venda para exercer a função de "olheiro". Não trazia nada consigo, o outro rapaz que estava com ele e se evadiu exercia a venda. Trabalhava na feira. Declarou-se arrependido. Tal confissão restou corroborada pelos demais elementos coligidos nos autos. Com efeito, o o policial civil Alexandre Cavalcante De Melo narrou que no dia dos fatos estava em operação

visando coibir a prática do tráfico e foi até o local conhecido como "comunidade da galinha", ponto de tráfico, e ao se aproximar da viela avistou duas pessoas encima da laje - o réu e outro indivíduo - além de outras três na parte debaixo. Foi para a laje enquanto seu parceiro ficou na parte debaixo. O réu desceu por um cano, caiu e foi abordado por seu parceiro. Já o outro indivíduo que estava encima da laje se evadiu pelos telhados. Em poder do réu nada de ilícito foi localizado. Eles descem a droga através de uma garrafa pet de cima da laje para os usuários que ficam embaixo. Não viu o réu realizando tal movimento. Na laje onde estava o acusado foi localizada uma sacola com as substâncias apreendidas - "cocaína" e "crack" -. Não se recorda a quantidade. Questionado, o réu disse que ganhava R\$ 100,00 por dia para exercer a função de "olheiro" para esse outro indivíduo. Os indivíduos se evadiram ao perceber a chegada da viatura. Não conhecia o réu anteriormente. No mesmo sentido o policial civil Antonio Bricio Farias afirmou que estava em operação de combate ao tráfico na região quando viu a movimentação na boca da favela, numa laje. Seu parceiro Alexandre foi para a laje e o réu desceu por um cano, momento que caiu e o deteve. Alexandre encontrou a sacola com as drogas na laje onde estava o réu com o outro indivíduo que se evadiu. Apenas os dois tinham acesso a tal laje. Realizada revista pessoal em poder do réu nada de ilícito foi localizado. Questionado, o réu disse que era "olheiro" e ganhava R\$ 100,00 por dia para olhar para o outro indivíduo que realizava a venda. Nunca tinha visto o réu anteriormente. O local é uma laje aberta em que eles descem as substâncias através de uma garrafa pet. Ressalto que o fato de os depoentes serem os policiais civis que prenderam o acusado em flagrante delito em nada desnatura seus depoimentos, pois "Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório" (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em 01.10.96). Os policiais sequer conheciam o denunciado quando da ocorrência, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, visto que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Ainda: "Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido." (JTJ 208/273). "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/275). Demais disso: "A prisão em flagrante é a mais cabal, a mais convincente das provas do crime e de sua autoria que a Justiça pode obter, desde que não encontre oposição formada em Juízo que a inutilize ou modifique. Assim, absurdo é que o julgador, ao formar livremente sua convicção, despreze o expressivo elemento" (JUTACRIM 43/251). Ressalto, outrossim, que a quantidade, diversidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas - 60 porções de "maconha" (com 95,3 g) + 221 porções de "cocaína" (com 212,2 g) - são circunstâncias que somadas ao local, que é conhecido ponto de tráfico, não deixam dúvidas que as substâncias se destinavam inequivocamente à traficância. Saliento, outrossim, que o réu, ainda que na função de "olheiro", estava no mesmo ambiente em que localizadas as drogas, ou seja, onde estavam sendo vendidas e guardadas, razão pela qual, na forma do art. 29, do Código Penal, praticou o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, com o que inviável a desclassificação delitiva pretendida pela d. Defesa. Comprovadas, assim, autoria e materialidade delitivas, o decreto condenatório é medida que se impõe. Passo, pois, à dosimetria da pena. Nos termos do artigo 59, do Código Penal, c.c. artigo 42, da Lei n.º 11.343/06, fixo a pena-base em cinco (05) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Na segunda fase de aplicação de pena, verifico que o acusado é menor relativo e confessou a acusação, contudo, sem reflexo no montante da pena, de acordo com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Observo,

outrossim, que aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, eis que o réu é primário, não se podendo presumir que integre organização criminosa ou se dedique à prática do delito, mormente diante dos documentos acostados pela d. Defesa. Todavia, considerada a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, diminuo a pena anteriormente aplicada em metade (1/2), resultando a reprimenda corporal em dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa. Considerando a pena ora aplicada e primariedade do réu, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal (art. 33, do C.P.). Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar Kaio Gabriel Fernandes do Nascimento, qualificado nos autos, à pena de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incursão no artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06. Em decorrência do preceituado no artigo 44, do Código Penal, considerando que o réu é primário, menor de vinte e um anos, substituo a pena privativa de liberdade imposta pela pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena reclusiva, em local a ser fixado pelo juízo da execução, e por uma pena de multa, fixada em dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo legal vigente à época dos fatos e desde então corrigidos. Importante anotar que a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade e por multa não prejudica o regular pagamento da pena de multa imposta, originalmente, de forma cumulativa, permanecendo exigível. Em razão da pena ora fixada, o réu poderá apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento encaminhando-se à V.E.C. competente e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso II, da Constituição Federal. Autorizo a destruição dos objetos e das substâncias entorpecentes apreendidas. Oficie-se. Isento de custas. Publicada em audiência. Saem os presentes cientes e intimados."

Dada a palavra ao (à) Dr. (a). Promotor (a) de Justiça, pelo (a) mesmo (o) foi dito que: MMª Juíza, Ciente da sentença, este (esta) Promotor (a) de Justiça não apela.

Dada a palavra ao (à) Dr (a). Defensor (a), foi dito: Ciente da sentença. Desejo apelar da decisão.

O réu tomou ciência da sentença e manifestou o desejo de recorrer da decisão.

Em seguida, pela MM. Juíza foi dito que: Recebo o recurso de apelação interposto pela D. Defesa. Processe-se-o. Diante da manifestação do Ministério Público em não recorrer certifique-se o trânsito em julgado. Oportunamente, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a observância das formalidades legais.

Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Eu, Luciana Emiko Fukassawa, Assistente Judiciário, digitei e assino digitalmente.